

1503612-47.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes:

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503612-47.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503612-47.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO FUZINELLI DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

O réu DIOGO FUZINELLI DA SILVA encontra-se denunciado pela suposta prática do delito capitulado pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denuncia que, na data de 24 de novembro de 2021, na Avenida Frei João das Mercês, próximo ao numeral 725, Parque Nossa Senhora das Dores II, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, aproximadamente 47,77g (quarenta e sete gramas e setenta e sete decigramas), divididas em 13 porções de "Cannabis Sativa L",

vulgarmente conhecida como Maconha, e também aproximadamente 4,96g (quatro gramas e noventa e seis decigramas), divididas em 13 porções de Cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os fatos narrados na denúncia a qual me reporto.

Recebida a denúncia, devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 127/131).

Regularmente processado, foram ouvidas as testemunhas arroladas e promovido o interrogatório (fls. 177/178).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, ante a existência de prova suficiente da autoria e materialidade.

A defesa por sua vez, também em memorial, sustentou em preliminar a ilicitude na busca pessoal, e no mérito, ser hipótese de absolvição, em virtude da insuficiência probatória.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria preliminar suscitada pela defesa – eventual ilicitude da busca pessoal - confunde-se com o próprio mérito da causa, devendo com ele ser analisada.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 20/24), laudo de constatação provisória (fls. 25/28), laudo de exame químico toxicológico (fls. 82/84) e pela prova testemunhal.

Do mesmo modo, a autoria é certa e recai sobre o réu.

Ao ser interrogado em sede policial, o réu negou os fatos (fl. 07/08). Consignou que portava apenas três "buchas" de maconha encontradas consigo, para uso pessoal. Que as demais drogas encontradas pertenciam aos traficantes que lhe venderam as porções de maconha, e que foram liberados pelos policiais, tendo sido incriminado indevidamente.

Ao ser ouvido em juízo, manteve a mesma versão, negando a prática do delito, reforçando tratar-se de mero usuário de maconha.

Ocorre que, a versão trazida pelo acusado restou isolada no conjunto probatório.

Com efeito, os dois policiais militares ouvidos em juízo apresentaram narrativa coincidente, confirmando os fatos descritos na denúncia.

O policial militar Marcelo Machado de Souza e seu colega de farda, Renato de Souza Andrade, esclareceram terem avistado o réu em postura suspeita em área já conhecida como ponto de tráfico, realizaram a abordagem, encontrando com o acusado três porções de maconha, sendo que, indagado, admitiu manter escondidas outras porções de maconha e cocaína, para fins de tráfico, indicando o local.

As testemunhas não puderam certificar-se da prática de efetivo ato de mercancia, no entanto, a conduta descrita na denúncia, "manter em depósito" e "trazer consigo, para fins de tráfico", compõe o tipo alternativo previsto pelo art. 33 da Lei de Drogas e veio devidamente amparada nos autos.

A quantidade de droga apreendida é considerável, ao menos no que diz respeito à

verificação dos propósitos de aquisição para consumo próprio. Entendo que a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente é meio de prova do comércio e não mera presunção. É claro que, por si só, a quantidade não é suficiente para reconhecer o tráfico, mas, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, como ocorreu no caso, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

A jurisprudência tem se alinhado à tese de que a quantidade do entorpecente, aliada a outros aspectos, é meio hábil para a caracterização do tráfico de entorpecentes:

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO FALCÃO, RJTJSP 84/382).

Ademais, a análise da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n.11343/06 deve ser feita em conformidade com o contexto apresentado, de forma que o conjunto de elementos somados uns aos outros, por intermédio do raciocínio indutivo, faça "crescer o conhecimento do ser humano, unindo-se dados parciais para formar um quadro mais amplo" (NUCCI, CPP Comentado, p. 521, 9. Ed, RT).

De fato, a prova do crime no presente caso é valorada pelo conjunto de indícios, que de acordo com as ponderações do consagrado doutrinador GUILHERME DESOUZA NUCCI "são perfeitos tanto para sustentar uma condenação quanto uma absolvição", ressaltando que "há autorização legal para a sua utilização e não se pode descuidar que há muito preconceito contra esse espécie de prova, embora seja imprescindível ao juiz utilizá-la" (Op. Cit., p. 514).

Não há indicativo de abuso dos policiais, que realizaram a abordagem com fundamento em suspeitas plenamente justificadas, tanto que encontradas porções significativas de entorpecentes. Note-se que uma pessoa parada num ponto de tráfico, revela postura suspeita, não se tratando de mero palpite aleatório dos policiais, tampouco preconceito.

No mais, não há qualquer indícios de que os policiais teriam "forjado" as porções, ou seja, obtido previamente a droga em outra ação e, de forma criminoso, imputado a posse ao acusado de forma gratuita, com o único propósito de incriminá-lo.

Sob este prisma, não se ignora que o relato de agentes estatais, naturalmente interessados diretamente na avaliação positiva de suas condutas, deva ser considerado com cautela pelo julgador. No entanto, a bem da verdade, todo e qualquer testemunho ou relato deve sempre ser analisado com cuidado pelo juiz, uma vez que é bastante provável que, por exemplo, a vítima tenha a tendência de "enxergar" os fatos de modo mais favorável a si, ou que as testemunhas procurem tornar suas declarações o mais convincentes possível.

Dessa forma, deve sempre o magistrado proferir sua decisão de acordo como chamado livre convencimento motivado, fundamentando-a nos diversos elementos dos autos, admitindo-se a condenação quando estes se mostrem harmônicos, não se prescindindo da existência de prova colhida em contraditório judicial.

No caso em tela, portanto, não se demonstrando interesse pessoal dos agentes no objeto da investigação, tendo suas declarações sido confirmadas, em essência, pelos demais indícios dos autos, havendo coerência e verossimilhança nos relatos, evidente que se pode levá-los em conta para um decreto condenatório.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC nº 74.608-0-SP - Rel. Min Celso de Mello). Assim, resta incontroversa a realização da conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, consideradas todas as circunstâncias da prisão em flagrante, a localização das diversas porções e tipos de drogas, a quantidade não desprezível, a forma como estavam acondicionadas, bem como a versão pouco convincente apresentada pelo acusado, tem-se como certa a prática da atividade de tráfico ilícito.

Assim sendo, indubitosa a necessidade da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para o tipo estabelecido no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, no que se refere aos motivos do crime, suas consequências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade dos antecedentes, tem-se que não há qualquer elemento que torne as condutas do réu mais fortemente reprováveis além do que já previsto no tipo penal em abstrato.

Quanto às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no sentido de que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, é de se reconhecer que a não muito alta quantidade de droga, mas suficiente para se ter, diante das circunstâncias do caso, como incompatível para o uso, não enseja a elevação da pena-base.

Desse modo, considerando-se os elementos analisados acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de multa 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da menoridade relativa, mas que não permite a redução da pena a patamar inferior ao mínimo.

Na terceira fase, cabe apreciar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Nesse aspecto, embora o réu seja tecnicamente primário, ostenta antecedentes infracionais relacionados ao tráfico de drogas, circunstância elucidativa de seu constante envolvimento com comércio ilícito de entorpecentes, desde o período de menoridade.

Os processos indicados à fl. 38/39 dão conta de envolvimento com a práticas de ilícitos desde o ano de 2016, época em que contava com apenas treze anos de idade (início da adolescência), e a despeito de ter sido submetido a diversas medidas sócio-educativas pela prática de ato infracional correspondente ao tráfico, lamentavelmente manteve os vínculos relacionados ao comércio de drogas por longo período de tempo.

Sob esse aspecto, importa mencionar apenas algumas das condenações suportadas pelo adolescente, nesta vara, que acumula jurisdição menorista:

- 1) autos 0002605-70.2016.8.26.0320, onde foi condenado, por sentença proferida nesta vara (que acumula jurisdição menorista) em 15 de dezembro de 2016, a medida sócio-educativa de internação pela prática do tráfico de drogas, tendo havido recurso de apelação, prolatado em 29 de maio de 2017, com negativa de provimento;
- 2) dos autos n. 1501286.85.2019.8.26.0320, onde foi condenado, em nova sentença proferida nesta vara, datada de 10 de maio de 2019, a medida sócio-educativa de internação pela prática do tráfico de drogas, tendo havido o trânsito em julgado;
- 3) autos 1503221-29.2020.8.26.0320, com data de 20 de outubro de 2020, foi novamente condenado por tráfico de drogas, e a despeito da interposição de recurso de apelação, foi negado provimento ao recurso, conforme acórdão prolatado em 15 de março de 2021.

Estes três processos são apenas exemplos pinçados dos extensos registros de fls. 37/39, onde se constata, sem qualquer dúvida, o envolvimento profundo e permanente do acusado com a criminalidade organizada, e ainda que seja jovem e primário, absolutamente inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, até porque, diante do quadro apresentado, qualquer redução da reprimenda, ou aplicação de pena alternativa, seriam absolutamente inúteis, pois já foram promovidas inúmeras tentativas de correção dos desvios de conduta pela via pedagógica, sem qualquer êxito.

A corroborar o entendimento de que antecedentes infracionais, devidamente motivados, podem servir como obstáculo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, traz-se a título exemplificativo o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de Entorpecentes. Impossibilidade de concessão do acordo de não persecução penal. Registro de outros processos em curso, inclusive pelo mesmo delito, e redutor que não foi incluído na denúncia. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão e validade dos depoimentos dos guardas civis e de testemunha isenta. Manutenção da majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. Irrelevância do fechamento das escolas porque havia proximidade, também, de unidade de saúde. Não é necessário, para a incidência da causa de aumento, que o tráfico tenha por objetivo afetar os frequentadores dos locais listados no dispositivo. Precedentes. Condenação acertada. Pena reduzida. Impossibilidade de valoração de processos em curso como maus antecedentes. Circunstância, contudo, que, aliada aos atos infracionais pretéritos evidenciam a dedicação do agente às atividades criminosas e impedem a concessão do redutor da Lei de Tóxicos. Regime fechado mantido em razão do histórico delitivo, da gravidade do crime e natureza do tóxico. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501260-76.2020.8.26.0571; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 01/07/2021) grifei

Assim, não fazendo o acusado jus ao benefício da redução de pena, resta-lhe a pena mínima prevista na cabeça do tipo penal, de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado DIOGO FUZINELLI DA SILVA, a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O regime inicial de cumprimento da pena de será o semiaberto, ante a ausência de reincidência e maus antecedentes (os antecedentes infracionais prestam-se unicamente a afastar a figura privilegiada).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, seja pelo montante de pena aplicada, seja pelo caráter hediondo do delito, seja porque não recomendável diante de todas as circunstâncias mencionadas.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que não surgiram novos fatos ensejadores da revogação da custódia cautelar, além do que, evidente o risco à ordem pública, pelas notícias de reiteraões praticadas pelo acusado, a tornar legítimo o receio de que a ordem pública seja afetada com a sua liberação. No mais, não há incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, devendo a detração ser analisada em sede de execução provisória, expedindo-se guia oportunamente.

Determino a destruição da droga apreendida.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

PIC

Limeira, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA